

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

**nr. 244.274 van 25 april 2019
in de zaak A. 227.744/XII-8713**

In zake: de NV LDV UNITED
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Philip Peerens en Sébastien Elst
kantoor houdend te 1170 Brussel
Terhulpsessesteenweg 166
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE GEMEENSCHAP
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten David D’Hooghe en Matthias De Groot
kantoor houdend te 1000 Brussel
Loksumstraat 25
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 28 maart 2019, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[d]e beslissing van de [Vlaamse Gemeenschap – Departementen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin] meegedeeld per schrijven d.d. 13 maart 2019, waarbij wordt beslist om de offerte van [de nv LDV United] voor de overheidsopdracht ‘Strategische en conceptuele begeleiding van verschillende communicatieprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ onregelmatig te verklaren en te weren, en om de opdracht te gunnen aan een andere inschrijver.”

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 16 april 2019, om 11.00 uur.

Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Philip Peerens, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Matthias De Groot, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De Vlaamse Gemeenschap – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, schrijft een overheidsopdracht uit met als voorwerp “Strategische en conceptuele begeleiding van verschillende communicatieprojecten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”.

De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 23 augustus 2018 en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie op 24 augustus 2018.

De opdracht wordt gegund via een niet-openbare procedure.

3.2. Met een beslissing van 16 november 2018 worden de volgende kandidaten geselecteerd en uitgenodigd tot het indienen van een offerte :

- Absoluut, zijnde de gekozen inschrijver
- Choco CVBA
- LDV United, zijnde de verzoekende partij
- Prophets
- RCA Group NV.

3.3. De geselecteerde ondernemingen ontvangen vervolgens het op deze opdracht toepasselijke bestek.

Wat de gunningscriteria betreft bepaalt het bestek wat volgt:

“

A.5. GUNNINGSCRITERIA

De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen rekening houdende met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die als volgt wordt ingevuld:

De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht:

- Wijze van uitwerking van de voorbeeldcampagne: 35 %
- De kwaliteit van het team dat aan de communicatieprojecten zal werken: 20 %
- De prijs: 45 %

”

Het bestek beschrijft voorts dat het prijscriterium wordt beoordeeld op basis van de totaalprijs btw inbegrepen, ingevuld in de inventaris (70%), en op grond van de prijs van de voorbeeldcampagne (30%).

Wat het subcriterium 3.1 “Eenhedsprijzen per uur” betreft, bepaalt het bestek:

“

3.1 de eenheidsprijzen per uur: 70%

De inschrijver wordt verzocht in de inventaris duidelijk de volgende prijsgegevens in euro te vermelden, zowel inclusief als exclusief btw.

Eenheidsprijzen per uur voor:

- a) Deelname aan overlegvergaderingen (bijvoorbeeld kabinet – administratie - opdrachtnemer): dit wordt aangerekend als één van de onderstaande profielen deelneemt aan een vergadering. De uren van deze profielen worden dan niet apart aangerekend.
- b) Accountmanager (aanspreekpunt voor de besteller, verantwoordelijk voor dagdagelijkse opvolging en coördinatie)
- c) Communicatiestrateg
- d) Art Director (vertaalt de strategie en doelstellingen van de besteller naar creatieve concepten in beeld)
- e) Creative director (supervisie van de creatievelingen en hoofverantwoordelijke voor alle creatieve vertalingen)
- f) Lay-outer/ Desktoppublisher (DTP'er)
- g) Copywriter (bedenken, schrijven, herschrijven teksten)
- h) Digital project manager

Dit hoofdcriterium wordt beoordeeld op basis van de totaalprijs incl. BTW ingevuld in de inventaris. De totale prijs incl. BTW, ingevuld in de inventaris, wordt geëvalueerd op basis van de volgende formule:

$$P = 70 \times P_m/P_o$$

Waarbij P het aantal punten is dat aan de inschrijver wordt toegekend voor het criterium “Prijs; P_m de laagste globale prijs inclusief BTW (basis), die door een inschrijver in een regelmatige offerte wordt voorgesteld;

P_o de globale prijs inclusief BTW (basis), die wordt voorgesteld door de inschrijver van wie de offerte wordt geëvalueerd.

De gemiddelde eenheidsprijs van de inschrijvers werd gelijkgesteld aan 70%

”

Wat het subcriterium “3.2. voorbeeldcampagne” betreft, bepaalt het bestek:

“3.2 de prijs van de voorbeeldcampagne: 30%

Hierbij wordt beoordeeld of de prijs in overeenstemming is met de geleverde kwantiteit en kwaliteit van producten en dienstverlening.”

Omtrent de prijsvaststelling van de opdracht bepaalt artikel A.4.1 van het bestek:

“

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING)

Deze opdracht is een opdracht met gemengde prijsvaststelling.

a) Onderdelen van de opdracht volgens een prijslijst.

De vermelde posten zijn forfaitaire eenheidsprijzen. Het uiteindelijk uit te betalen bedrag zal worden vastgesteld door de eenheidsprijzen te vermenigvuldigen met de hoeveelheden van de werkelijk verrichte prestaties.

De inschrijver dient voor de delen volgens prijslijst alle velden in de inventaris in het offerte-formulier in te vullen. De opdrachtnemer moet de finaal overeengekomen tarieflijst hanteren bij de uitvoering van opdrachten.

b) Onderdelen van de opdracht tegen terugbetaling:

Als de inschrijver kosten maakt die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, dan kunnen deze vergoed worden tegen terugbetaling. Het gaat dan om de prijs die de opdrachtnemer betaalt aan derden, zonder winstmarge voor de dienstverlening van de opdrachtnemer: alle andere kosten die niet in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen (bv. aankoop externe adressenbestanden, aankoop fotomateriaal, standmateriaal, displays, occasioneel drukwerk, vertalingen, ...), mits voorlegging van de bewijsstukken en op voorafgaande vraag en uitdrukkelijke goedkeuring van de besteller. Dit houdt ook de diensten in die de opdrachtnemer door een onderaannemer laat uitvoeren en die niet in de prijslijst zijn opgenomen.

”

3.4. De volgende inschrijvers dienen een offerte in :

- Absoluut, zijnde de gekozen inschrijver
- nv LDV United, de verzoekende partij
- Prophets
- nv RCA Group.

3.5. Op 11 maart 2019 wordt een gunningsverslag opgesteld. Daarin wordt met betrekking tot het regelmatigheidsonderzoek voor de offerte van de verzoekende partij vermeld :

“

- LDV United

In de offerte van LDV United NV wordt door de inschrijver bij de facturatie een productiefte van 5% en mediafee van 1% op de onderdelen tegen terugbetaling aangerekend. Dit is niet conform het bestek. Het bestek bepaalt namelijk in punt A.4.1 omtrent prijsvaststelling dat, in geval van onderdelen tegen werkelijke terugbetaling, er geen winstmarge voor de opdrachtnemer mag zijn op de prijs die de opdrachtnemer aan een onderaannemer betaalt.

Deze niet-conformiteit heeft de onvergelykbaarheid van de offerte met de andere offertes tot gevolg. De niet-conformiteit toch aanvaarden zou bovendien tot een discriminerend voordeel leiden voor de inschrijver. Om die redenen wordt de offerte van LDV United NV op basis van artikel 76 KB Plaatsing als substantieel onregelmatig beschouwd en bijgevolg geweerd.

”

In het gunningsverslag wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan Absoluut.

3.6. Bij een beslissing van niet vermelde datum sluit de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zich aan bij de motivering en het besluit van het gunningsverslag van 11 maart 2019, dat als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd en er integraal deel van uitmaakt, en beslist de offerte van de verzoekende partij te weren en de opdracht te gunnen aan Absoluut.

Dit is de bestreden beslissing.

Met een aangetekend schrijven van 12 maart 2019, elektronisch ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 13 maart 2019, wordt aan de verzoekende partij meegedeeld dat haar offerte onregelmatig werd verklaard en werd geweerd. Bij deze mededeling wordt een uittreksel uit het gunningsverslag gevoegd.

IV. Schorsingsvoorwaarden

4.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

4.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan verantwoorden.

V. Onderzoek van het enig middel

Uiteenzetting

5.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van:

“de artikelen 4, 81 en 84 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, van de artikelen 35 en 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, van het gelijkheids-, zorgvuldigheids- en transparantiebeginsel, en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, het principe van de manifeste beoordelingsfout en het principe ‘patere legem quam ipse fecisti’.

Doordat middels de bestreden beslissing de opdracht wordt gegund aan een ander inschrijver na de offerte van verzoekster onregelmatig te verklaren en te weren wegens substantiële onregelmatigheid, daartoe motiverend dat:
[...]

En dit zonder vooraf bij Verzoekster inlichtingen op te vragen omtrent de betekenis van de bedoelde productiefee en mediafee [...];

Terwijl in de door Verzoekster bij de offerte gevoegde documenten waarin de door haar geboden prijzen worden opgegeven, met name het offerteformulier en de inventaris opgesteld volgens het bij het bestek gevoegde model, geen sprake is van welkdanige bij bestek verboden winstmarge op prijzen van onderaannemers;

En terwijl de door Verwerende Partij geviseerde vermelding van een ‘productieftee’ en ‘mediafee’ in het bij de offerte van verzoekerster gevoegde document ‘voorstel’ van voorbeeldcampagne, in werkelijkheid louter een bij bestek toegelaten ereloon betreft voor eigen, aan uurtarief te leveren prestaties in de marge van productie- en mediabestellingen bij onderaannemers, en dus geen verboden winstmarge op prijzen te betalen aan onderaannemers;

En terwijl in het bedoelde document ‘Voorstel’ van voorbeeldcampagne, om elke twijfel omtrent de betekenis van deze ‘productieftee’ en ‘mediafee’ weg te nemen, hieromtrent uitdrukkelijk werd bepaald [...] ‘2.Onafhankelijk van productie- of mediacommissies (bij facturatie langs LDV United zal er een productieftee van 5% en mediafee van 1% aangerekend worden)’, waarbij de vermelding ‘onafhankelijk van commissies’ erop duidt dat geen verboden commissies op prijzen van onderaannemers zullen worden aangerekend, doch enkel ‘fees’ of erelonen wegens effectief geleverde prestaties, die conform het bestek per uurtarief dienen te worden aangerekend en waarbij de bij de fees vermelde percentages louter duiden op de inschatting van de relatieve waarde van die erelonen.

En terwijl de door het enige middel geviseerde bepalingen en principes onder meer vereisen dat overheidsopdrachten worden gegund aan de economisch meest voordelige offerte (artikel 81 van de wet overheidsopdrachten) waarbij offertes slechts kunnen worden geweerd wegens onregelmatigheid indien de offerte wordt aangetast door een substantiële onregelmatigheid of door meerdere niet-substantiële onregelmatigheden wanneer de cumulatie of combinatie ervan dezelfde gevolgen heeft als een substantiële onregelmatigheid (artikel 76,§3 KB Plaatsing) en waarbij het onderzoek naar de regelmatigheid van de offertes op een zorgvuldige wijze (zorgvuldigheidsbeginsel) en oordeelkundig (zonder manifeste beoordelingsfouten) dient te geschieden, met inachtnaam van de beginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit (artikel 4 van de wet overheidsopdrachten en het patere legem principe) en waarbij wanneer het gaat om het onderzoek van de aangeboden prijzen de overheid alle voor dit onderzoek dienstige inlichtingen kan opvragen bij de inschrijvers (artikel 84 van de wet overheidsopdrachten en artikel 35 van het KB Plaatsing).”

De verzoekende partij voert in dit middel in essentie aan dat de verwerende partij de aangehaalde bepalingen en beginselen heeft geschonden door de productfee en mediafee die door de verzoekende partij worden vermeld in haar voorstel van voorbeeldcampagne te beschouwen als een door het bestek verboden winstmarge op de prestaties van onderaannemers en door om die reden de offerte van de verzoekende partij substantieel onregelmatig te verklaren, terwijl het volgens haar enkel gaat om een bij het bestek toegelaten ereloon voor eigen, aan uurtarief te leveren prestaties in de marge van productie- en mediabestellingen bij onderaannemers.

Beoordeling

5.2. Met betrekking tot de prijsvaststelling wordt in het bestek bepaald wat volgt:

“A.4.1. PRIJSVASTELLING (ART. 26 KB PLAATSING)

Deze opdracht is een opdracht met gemengde prijsvaststelling.

a) Onderdelen van de opdracht volgens een prijslijst.

De vermelde posten zijn forfaitaire eenheidsprijzen. Het uiteindelijk te betalen bedrag zal worden vastgesteld door de eenheidsprijzen te vermenigvuldigen met de hoeveelheden van de werkelijk verrichte prestaties.

De inschrijver dient voor de delen volgens prijslijst alle velden in de inventaris in het offerteformulier in te vullen. De opdrachtnemer moet de finaal overeengekomen tarieflijst hanteren bij de uitvoering van opdrachten.

b) Onderdelen van de opdracht tegen terugbetaling:

Als de inschrijver kosten maakt die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, dan kunnen deze vergoed worden tegen terugbetaling. Het gaat dan om de prijs die de opdrachtnemer betaalt aan derden, zonder winstmarge voor de dienstverlening van de opdrachtnemer: alle andere kosten die niet in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen (bv. aankoop externe adressenbestanden, aankoop fotomateriaal, standmateriaal, displays, occasioneel drukwerk, vertalingen, ...) mits voorlegging van de bewijsstukken en op voorafgaande vraag en uitdrukkelijke goedkeuring van de besteller.”

Bij het bestek is een inventaris gevoegd die door de inschrijvers dient te worden ingevuld voor de onderdelen van de opdracht volgens prijslijst. Op deze inventaris zijn de volgende posten vermeld waarvoor de inschrijvers een prijs per uur dienen op te geven:

- Deelname aan overlegvergaderingen
- Accountmanager
- Communicatiestrategie
- Art director
- Creative director
- Lay-outer/DTP'er
- Copywriter
- Digital project manager.

Hieruit volgt dat de inschrijvers in hun offerte enkel een eenheidsprijs dienen op te geven voor de diverse posten opgenomen in de inventaris. Voor de mogelijke terugbetaling van prestaties geleverd door derden die niet in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen, dient geen prijs te worden opgegeven. Er wordt in het bestek hieromtrent wel uitdrukkelijk bepaald dat hiervoor enkel de prijs wordt terugbetaald die de dienstverlener zelf betaalt aan derden, zonder dat daarop een winstmarge mag worden aangerekend door de dienstverlener. Uit deze besteksbepaling blijkt op het eerste gezicht voldoende duidelijk dat de inschrijver in zijn prijsopgave in geen toeslag bestaande uit een winstmarge mag voorzien op de kostprijs van de prestaties die geleverd zullen worden door onderaannemers.

5.3. De verzoekende partij heeft op het eerste gezicht de inventaris gevoegd bij haar offerte ingevuld in overeenstemming met de vereisten van het bestek waarbij zij telkens voor elke post een eenheidsprijs (te dezen een uurprijs) heeft opgegeven.

Naast de prijzen vermeld in de inventaris heeft de verzoekende partij echter in haar offerte op twee plaatsen aangegeven dat zij een toeslag zal aanrekenen op prestaties geleverd door derden dan wel op de andere kosten die niet in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen, zoals onder meer het aanleveren van fotomateriaal en drukwerk. Zo wordt op bladzijde 52 van de offerte, onder de titel “Transparantie: garanties” vermeld dat onafhankelijk van productie- of media-commissie bij facturatie langs LDV United een productiefee van 5% en een mediafee van 1% wordt aangerekend. Daarnaast wordt ook in de prijsopgave op bladzijden 69 en 70 voor de voorbeeldcampagne “Geïntegreerd breed onthaal” vermeld dat een productiefee van 5% op fotografie/drukwerk/online video/gravure wordt aangerekend. De opgave van de prijs voor deze voorbeeldcampagne kadert binnen de beoordeling van het tweede subcriterium binnen het gunningscriterium “prijs”. Voor de beoordeling van het prijscriterium wordt immers volgens de bepalingen van het bestek enerzijds de totaalprijs van de offerte vergeleken berekend op basis van de eenheidsprijzen in de inventaris (weging 70%), en wordt

daarnaast beoordeeld of de opgegeven prijs voor de voorbeeldcampagne “Geïntegreerd breed onthaal” in overeenstemming is met de geleverde kwaliteit en kwantiteit (weging 30%).

5.4. Gelet op de voormelde elementen uit de offerte van de verzoekende partij lijkt de verwerende partij op het eerste gezicht niet buiten de grenzen van de haar toekomstige beoordelingsruimte te zijn getreden door aan te nemen dat de verzoekende partij in haar offerte, in afwijking van wat in het bestek werd bepaald, toch een toeslag aanrekent, namelijk een productiefee en een mediafee, op de andere kosten die niet in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen (bijvoorbeeld aankoop externe adressenbestanden, aankoop fotomateriaal, standmateriaal, displays, occasioneel drukwerk, vertalingen).

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar verzoekschrift betoogt, staat op grond van het feit dat de door haar aangeboden prijzen enkel worden vermeld in het offerteformulier en in de inventaris en er in geen van die documenten sprake is van een door het bestek verboden winstmarge, op het eerste gezicht niet vast dat zij zich verbonden heeft om enkel de eenheidsprijzen meer de aan derden te betalen prijzen zonder winstmarge te hanteren bij de gunning van de opdracht. Immers, de wijze van prijsopgave zoals vereist door het bestek leidt ertoe dat in de inventaris enkel de eenheidsprijzen dienen te worden vermeld voor de uurtarieven van de medewerkers van de verzoekende partij. De kosten die de dienstverlener in rekening zal brengen voor de door derden geleverde prestaties, zoals het aanleveren van drukwerk, fotomateriaal en dergelijke, dienden niet in de inventaris te worden opgenomen. In het kader van de prijsopgave voor de voorbeeldcampagne diende echter wel een inschatting te worden gemaakt van deze kosten voor die betreffende voorbeeldcampagne en daar heeft de verzoekende partij wel uitdrukkelijk melding gemaakt van het aanrekenen van een productiefee van 5% op deze kosten. Bovendien werd ook nog op een andere plaats in de offerte uitdrukkelijk gesteld dat een productiefee van 5% en een mediafee van 1% wordt aangerekend bij facturatie langs LDV United. In die omstandigheden lijkt de verwerende partij niet buiten de grenzen van de haar toekomstige beoordelingsruimte te zijn getreden door aan te nemen dat deze vermelding inzake de prijs

tevens deel uitmaakte van de offerte.

Evenmin kan de argumentatie van de verzoekende partij worden bijgevalen dat uit de melding op bladzijde van 52 van haar offerte dat een productie- en mediafee wordt aangerekend “onafhankelijk van productie- of mediacommissies” duidelijk zou blijken dat het niet haar bedoeling was een door het bestek verboden winstmarge aan te rekenen. Immers, in de daaropvolgende zin uit haar offerte wordt uitdrukkelijk aangegeven dat wel een productiefee en mediafee wordt aangerekend bij facturatie langs LDV United. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij thans in haar verzoekschrift betoogt, lijkt op het eerste gezicht niet te kunnen worden aangenomen dat zij met deze vermelding in haar offerte bedoelde dat er fees of erelonen zouden worden aangerekend overeenkomstig de tarieven uit de inventaris voor de hiervoor extra door haar medewerkers te leveren prestaties. Uit de wijze waarop de verzoekende partij de prijsopgave voor de voorbeeldcampagne heeft opgesteld, blijkt immers op het eerste gezicht dat zij zowel eenheidsprijzen per uur en totaalprijzen voor de door haar medewerkers te leveren prestaties heeft opgegeven, waarbij zij een inschatting heeft gemaakt van deze prestaties, als daarnaast nog een productiefee van 5% op het aan te leveren drukwerk/fotomateriaal/etc. Dat deze “fee” louter een inschatting van de totaalprijs zou zijn van de door de verzoekende partij te leveren eigen prestaties in de marge van de productie- en of mediabestellingen bij derden kan op het eerste gezicht evenmin worden bijgevalen. Immers de prijsopgave voor de overige prestaties van haar personeelsleden in de voorbeeldcampagne vormen ook slechts een inschatting van de werkelijk te leveren prestaties, en hiervoor heeft zij wel een totaalprijs opgegeven gegrond op het geschatte aantal uren vermenigvuldigd met de eenheidsprijs voor elke medewerker. Er valt op het eerste gezicht niet in te zien waarom het onmogelijk zou zijn geweest de inschatting van de te leveren prestaties in de marge van de productie- en of mediabestellingen niet bij op te nemen in de totaalprijs voor elke medewerker voor de diverse onderdelen van de voorbeeldcampagne, zoals dit volgens de posten opgenomen in de inventaris diende te gebeuren. Zoals de verwerende partij terecht in haar nota aangeeft, was de verzoekende partij volgens de bepalingen van het bestek verplicht om alle door

haar medewerkers te leveren prestaties in het kader van de te leveren diensten op te nemen in de inventaris.

Door in het kader van de prijsopgave voor de voorbeeld-campagne de prijs voor de prestaties van de medewerkers in de marge van de productie- en of mediabestellingen af te splitsen van de andere prestaties die de medewerkers leverden en hiervoor een percentage aan te rekenen op de kosten van onder meer het drukwerk en fotomateriaal en dit in combinatie gelezen met de vermelding op bladzijde 52 van haar offerte dat een productiefee en mediafee worden aangerekend bij facturatie langs LDV United, terwijl het niet de bedoeling zou zijn geweest een extra fee aan te rekenen, heeft de verzoekende partij zelf een onduidelijkheid gecreëerd in haar offerte die de verwerende partij in alle redelijkheid mocht interpreteren op de wijze zoals vermeld in de bestreden beslissing.

In de mate dat de verzoekende partij voorts betoogt dat de verwerende partij hieromtrent verdere inlichtingen had dienen in te winnen bij de verzoekende partij in het kader van het prijsonderzoek zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 2017), valt op het eerste gezicht niet in te zien hoe uit deze bepaling een dergelijke verplichting zou voortvloeien met betrekking tot prijsgegevens waarover de verwerende partij reeds beschikt en die voor haar geen onduidelijkheid inhouden.

5.5. In de bestreden beslissing werd omtrent de offerte van de verzoekende partij geoordeeld:

“

- LDV United

In de offerte van LDV United NV wordt door de inschrijver bij de facturatie een productiefte van 5% en mediafee van 1% op de onderdelen tegen terugbetaling aangerekend. Dit is niet conform het bestek. Het bestek bepaalt namelijk in punt A.4.1 omtrent prijsvaststelling dat, in geval van onderdelen tegen werkelijke terugbetaling, er geen winstmarge voor de opdrachtnemer mag zijn op de prijs die de opdrachtnemer aan een onderaannemer betaalt.

Deze niet-conformiteit heeft de onvergelykbaarheid van de offerte met de andere offertes tot gevolg. De niet-conformiteit toch aanvaarden zou bovendien tot een discriminerend voordeel leiden voor de inschrijver. Om die redenen wordt de offerte van LDV United NV op basis van artikel 76 KB Plaatsing als substantieel onregelmatig beschouwd en bijgevolg geweerd.

”

De hiervoor vermelde product- en mediafee op de door derden te leveren prestaties voor de uitvoering van de opdracht werd door de aanbestedende overheid bijgevolg beschouwd als een afwijking van het bestek die de vergelijking van de offertes in het gedrang bracht en een discriminerend voordeel voor de verzoekende partij opleverde, redenen waarom de offerte substantieel onregelmatig werd verklaard.

Het geschonden geachte artikel 76 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, bepaalt in zijn paragraaf 1:

“§ 1. De aanbestedende overheid gaat na of de offertes regelmatig zijn.

De offerte kan substantieel of niet substantieel onregelmatig zijn.

Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend voordeel te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de andere offertes te verhinderen, of de verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren onbestaande, onvolledig of onzeker te maken.

De volgende onregelmatigheden worden met name als substantieel beschouwd :

1° de niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, voor zover deze niet-naleving strafrechtelijk gesanctioneerd wordt;

2° de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, eerste lid, 54, § 2, 55, 83 en 92 van dit besluit en in artikel 14 van de wet, voor zover zij verplichtingen bevatten ten aanzien van de inschrijvers;

3° de niet-naleving van de minimale eisen en de vereisten die als substantieel worden aangemerkt in de opdrachtdocumenten.”

5.6. Zoals uit de voorgaande beoordeling reeds is gebleken, lijkt de verwerende partij terecht tot de vaststelling te mogen zijn gekomen dat de wijze waarop de verzoekende partij haar prijzen in haar offerte heeft opgegeven, en meer bepaald het opnemen van een toeslag voor prestaties door derden in de prijsopgave voor de voorbeeldcampagne en ook elders in de offerte, afwijkt van de wijze van prijsvaststelling zoals beoogd in het bestek. Met de verwerende partij lijkt te moeten worden aangenomen dat een dergelijke afwijking van het bestek als een substantiële onregelmatigheid dient te worden beschouwd in de zin van het voormelde artikel 76, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing 2017. De door de verzoekende partij gehanteerde prijstoeslag lijkt immers zowel de prijsvergelijking met de andere inschrijvers, die geen afzonderlijke prijstoeslag hebben opgegeven, te verhinderen, als onzekerheid te creëren over de verbintenis van de verzoekende partij om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren, namelijk enkel en alleen aan een uurloon voor de verschillende profielen en voor deelname aan overlegvergaderingen zoals opgegeven in de inventaris bij de offerte en voor de totaalprijs opgegeven in het offerteformulier. Wat de mogelijks ongelijke behandeling betreft wijst de verwerende partij er in haar nota op het eerste gezicht terecht op dat de wijze waarop de verzoekende partij haar offerte heeft opgesteld, tot concurrentievervalsing aanleiding kan geven. Immers het bestek bepaalt dat het prijscriterium zal worden beoordeeld op de totaalprijs ingevuld in de inventaris en op grond van de prijs van de voorbeeldcampagne. Door de toeslag op prestaties geleverd door derden niet op te nemen in de inventaris van de offerte, maar enkel in de tekst van de offerte en in de prijsopgave voor de voorbeeldcampagne, zou bij de vergelijking van de offertes voor de beoordeling van het eerste subcriterium “prijs”, waar de laagste prijs de meeste punten verkreeg, voor de offerte van de verzoekende partij ten onrechte met een lagere prijs rekening worden gehouden, dit in strijd met de werkelijke prijs die zij volgens de verdere informatie in haar offerte zal aanrekenen.

Het lijkt dat aldus twee van de voorwaarden zijn vervuld om een offerte krachtens artikel 76, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 substantieel onregelmatig te bevinden.

Bijgevolg blijkt ook meteen dat de verwerende partij omtrent deze productie- en mediafee geen nadere inlichtingen had mogen vragen aan de verzoekende partij in het kader van het prijsonderzoek. Immers, enige toelichting omtrent deze prijsopgave had op het eerste gezicht aanleiding kunnen geven tot een wijziging van de offerte met betrekking tot een essentieel element, namelijk de prijs. De aanbestedende overheid dient daarentegen de regelmatigheid van de offertes in beginsel te beoordelen op grond van de offertes zelf en niet in het licht van aanvullende verklaringen die een wijziging van de offerte inhouden, en dit op straffe van een schending van de gelijke behandeling der inschrijvers. Het komt aan een inschrijver toe zijn offerte met de nodige zorgvuldigheid op te stellen. De verwerende partij wijst er terecht op dat, gelet op het uitdrukkelijke verbod in het bestek om een winstmarge aan te rekenen op prestaties uitgevoerd door onderaannemers in het kader van de opdracht, het aan de inschrijver toekwam zijn offerte op te stellen op een wijze die geen ruimte laat om te denken dat zij een winstmarge op de prestaties voor onderaannemers zou aanrekenen.

Het middel is dan ook niet ernstig in de mate daarin een schending wordt aangevoerd van de artikelen 4, 81 en 84 van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’, van de artikelen 35 en 76 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, noch van het gelijkheids-, het zorgvuldigheids- en het transparantiebeginsel, noch van het beginsel *patere legem quam ipse fecisti*, noch van “het principe van de manifeste beoordelingsfout”, wat als een schending van het materiële motiveringsbeginsel lijkt te moeten worden begrepen.

5.7. In de mate dat de verzoekende partij voorts de schending aanvoert van de formelemotiveringsverplichting, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen’, dient te worden vastgesteld dat zij op geen enkele wijze uiteenzet hoe deze bepalingen concreet zouden zijn geschonden, zodat het middel in zoverre niet ontvankelijk is. Hoe dan ook toont de verzoekende partij niet aan en valt ook niet meteen in te zien waarom de in de bestreden beslissing opgenomen motivering omtrent de onregelmatigverklaring van haar offerte haar niet in staat

stelde met kennis van zaken te oordelen of het zin had zich tegen de bestreden beslissing in rechte te verweren. Het uitvoerige betoog in haar verzoekschrift, waarbij zij de redenen voor onregelmatigverklaring tracht te weerleggen, toont veeleer het tegendeel aan.

Het middel is in zoverre evenmin ernstig.

VI. Besluit

6.1. Het enig middel is niet ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden verworpen.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt de vordering.

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 25 april 2019,
door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Johan Bovin,	staatsraad,
	waarnemend voorzitter,
bijgestaan door	
Silja Doms,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Silja Doms

Johan Bovin